

0002612-35.2017.8.26.0544

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Flávia Cristina Campos Luders

Comarca: Várzea Paulista

Foro: Foro de Várzea Paulista

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 29/04/2022

... Eu estou preso por envolvimento no tráfico de entorpecentes. Eu fui condenado. Eu não lembro de ter sido preso ou abordado na Rua Solimões, em Várzea Paulista. Eu fui preso em Jundiaí, no Jardim Esplanada."

Gustavo, policial civil, informou que "No dia dos fatos, nós fomos até o local indicado na denúncia, que é conhecido ponto de tráfico nesta cidade. Nós ficamos no local ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Várzea Paulista

Foro de Várzea Paulista

2ª Vara

Avenida Fernão Dias Leme, 2323 - Vila Santa Terezinha

CEP: 13220-005 - Várzea Paulista - SP

Telefone: (11) 3378-6476 - E-mail: varzeapta2@tjsp.jus.br

0002612-35.2017.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0002612-35.2017.8.26.0544

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DARIO DA SILVA CARDOSO e outro

Juíza de Direito: Dra. Flávia Cristina Campos Luders

Vistos.

1. DÁRIO DA SILVA CARDOSO, qualificado à fl. 17, está sendo processado como incurso no art. 33, caput, e no art. 35, caput, c.c. art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal, porque em 13 de dezembro de 2017, na Rua Solimões, 1697, Vila Popular, Várzea Paulista, nas imediações de sede de entidade social, cultural e beneficente, vendia, guardava e tinha em depósito, para o fim de tráfico e para entrega ao consumo de terceiros, 21 (vinte e uma) porções individualizadas de cocaína apresentadas na modalidade pedras de crack e 08 (oito) porções individualizadas de cocaína em pó, substâncias estas entorpecentes e capazes de determinar a dependência física ou psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

THALES MOREIRA RODRIGUES, qualificado indiretamente à fl. 41, está sendo processado como incurso no art. 33, caput, no art. 35, caput, c.c. art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, e no art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/13, todos na forma do art. 69 do Código Penal, porque em 13 de dezembro de 2017, na Rua Solimões, 1697, Vila Popular, Várzea Paulista, nas imediações de sede de entidade social, cultural e

beneficente, concorreu para a prática do crime de tráfico de entorpecentes fornecendo ou intermediando o fornecimento de drogas, mediante vínculo associativo, o que fez sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. DÁRIO DA SILVA CARDOSO e THALES MOREIRA RODRIGUES estão sendo processados porque em data incerta e até o dia 13 de dezembro de 2.017, na Rua Solimões, 1697, Vila Popular, Várzea Paulista, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Denúncia oferecida em 15 de janeiro de 2.018 (fls. 163/165) e recebida em 16 de janeiro de 2.018, oportunidade em que foi decretada a prisão preventiva de Thales (fls. 168/169 e 170).

Devidamente citados, Dário e Thales apresentaram a resposta à acusação (certidões de fl. 217 e 249 e fls. 222/226).

O recebimento da denúncia foi ratificado (fl. 233).

A prisão preventiva foi revogada em 12 de setembro de 2.018 (fls. 284/286).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação. Em seguida, procedeu-se ao interrogatório dos réus (fls. 287/289, 321, 393/394 e 395/396). Em debates orais, a representante do Ministério Público requereu sejam os réus condenados nos exatos termos da denúncia (fls. 391/392).

O defensor de Thales afirmou que o réu já foi condenado pela prática dos crimes descritos na denúncia (autos que tramitaram sob o número 0002536-11.2017.8.26.0544). Requereu seja acolhida a exceção de coisa julgada oposta com fundamento nos arts. 95 e 110 do Código de Processo Penal (fls. 400/403).

A patrona de Dário absolvido com fundamento no art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal (fls. 421/422).

É o relatório.

2. FUNDAMENTO E DECIDO.

REJEITO a exceção oposta pelo patrono de Thales.

Thales está sendo acusado nesses autos de envolvimento nos crimes previstos nos art. art. 33, caput, e art. 35, caput, c.c. art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, e art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/13, praticados em data distinta e que teriam contado, em tese, com a participação do corréu Dário.

Os fatos tratados nesses autos não guardam relação com aqueles apurados no feito que tramitou na 1ª Vara Judicial dessa comarca. Não há coisa julgada.

Ultrapassada essa questão, passo a analisar o mérito da ação penal.

A materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes restou cabalmente comprovada com o auto de exibição e apreensão de fls. 12, com o laudo de constatação de fls. 14/15, que resultou positivo para a substância cocaína e com o laudo de exame químico-toxicológico de fl. 200, igualmente positivo para as substâncias mencionadas.

A autoria é certa.

Ao ser ouvido na Delegacia de Polícia, Dário declarou que "já fui preso e condenado por tráfico de drogas. Esclareço que tenho 07 filhos, os quais estão com suas genitoras. Informo que após ocorrer diversas prisões próximo de minha casa, Thales, o "Irmão Mineiro", me chamou para vender drogas, como estou precisando de dinheiro aceitei. Escondia as drogas no corredor da minha casa. Nesta data vendia as drogas (cocaína e crack), quando fui abordado pelos policiais. Ao ser abordado, indiquei aos agentes onde escondia as drogas, em um buraco no corredor da entrada da minha casa. Nesta Delegacia de Polícia reconheci a fotografia de Thales Moreira Rodrigues, como sendo "Irmão Mineiro", indivíduo para quem eu vendia as drogas" (fl. 05).

Ao ser ouvido em juízo, Dário declarou que "eu não tenho que temer a Justiça. Eu conheço Thales aqui da vila, aqui do bairro só. Eu não sei se ele trafica. No dia dos fatos tinha uns caras vendendo droga do outro lado da rua. Eu estava sentado em frente à minha casa quando "a civil" chegou. Aqueles rapazes correram. Eu fui abordado pelos policiais civis. Os policiais perguntaram se eu sabia quem eram os traficantes. Eu respondi: "Vocês que são os policiais que têm que saber!". Eu sou usuário de maconha. Os policiais civis entraram em minha casa, revistaram tudo e "me arrastaram". Eu sou viúvo. Eu não ia traficar na porta da minha casa. Eles queriam R\$ 5.000,00. Eles disseram "aí a gente finge que nem te conhece". Os

policiais não acharam entorpecentes perto da minha casa. A droga apreendida foi encontrada "perto da caixa d'água", lá na Rua Pindaré. "Fica 5 minutos a pé". Eu nunca tinha sido abordado por policiais civis. Eu já fui processado e condenado anteriormente por envolvimento com o tráfico de entorpecentes. Na época eu estava trabalhando na construção civil. Eu estou trabalhando no açougue."

Ao ser ouvido em Juízo, Thales declarou que "eu fui preso no B0 que eu estou preso em Jundiá. Eu conheço o corréu de vista. Nós moramos na Vila Popular, em Várzea Paulista. Eu estou preso por envolvimento no tráfico de entorpecentes. Eu fui condenado. Eu não lembro de ter sido preso ou abordado na Rua Solimões, em Várzea Paulista. Eu fui preso em Jundiá, no Jardim Esplanada."

Gustavo, policial civil, informou que "No dia dos fatos, nós fomos até o local indicado na denúncia, que é conhecido ponto de tráfico nesta cidade. Nós ficamos no local por cinco ou dez minutos. Nós vimos o réu Dário parado em frente ao imóvel localizado na Rua Solimões, 1.697. Pelo que nós pudemos apurar, Dário residia neste local. Vimos quando Dário foi abordado por um indivíduo e, após um breve diálogo, Dário entrou no imóvel. Dário saiu do imóvel e entregou algo a este rapaz. Este rapaz estava a pé. Após receber algo das mãos de Dário, esse rapaz desceu a via. Pouco tempo depois, Dário foi abordado por um outro rapaz que estava em uma bicicleta. Após a abordagem, este rapaz ficou aguardando no portão da residência de Dário. Dário entrou no imóvel e retornou logo em seguida. Ele entregou algo a este rapaz que deixou o local na bicicleta. Em razão disso, nós resolvemos abordar Dário. Durante a revista pessoal, nada foi encontrado com Dário. Questionado, Dário disse que não tinha nenhum envolvimento no tráfico. Ele afirmou que não tinha entregado nada àqueles rapazes. Nós dissemos a Dário que ele tinha sido visto entregando algo àqueles rapazes. Ele mencionou que morava naquele imóvel com a esposa e um filho. Após alguma insistência, Dário admitiu que estava passando por dificuldades e que os entorpecentes estavam escondidos no corredor, na parte externa do imóvel. Dário indicou o local onde estavam escondidos os entorpecentes. Nós encontramos um saco plástico em um buraco na parede, do lado direito do corredor. Dentro do saco plástico havia 08 porções individualizadas de cocaína e diversas porções de crack, além da quantia de trinta reais em dinheiro. Dário admitiu que a quantia em dinheiro era proveniente da comercialização de entorpecentes. Todos os entorpecentes já estavam embalados em porções individualizadas, já prontos para comercialização. Dário informou que trabalhava para um indivíduo conhecido pela alcunha de "Irmão Mineiro". Dário disse que, aquele ponto de venda de drogas pertencia ao "Irmão Mineiro". Ele não mencionou de quem recebia os entorpecentes. Ele não disse para quem entregava o dinheiro obtido com a venda das drogas. Posteriormente, nós conseguimos apurar que Thales Moreira Rodrigues é o indivíduo conhecido pelo alcunha de "Irmão Mineiro". Nós conseguimos apurar que Thales é o "Irmão Mineiro" após a prisão da namorada dele. Eu não me recordo quem é a namorada de Thales. Nós conseguimos identificar Thales como sendo Irmão Mineiro após uma senhora ter sido presa também pela prática do crime de tráfico de entorpecentes. Ela disse que tinha sido abordada pela namorada de Thales pelo Facebook. Ela disse que foi contratada pelo tráfico porque estava passando por dificuldades financeiras e precisava de dinheiro para custear a festa de aniversário do filho. Ela mencionou que a namorada de Thales era uma moça ruiva. Passado algum tempo, nós conseguimos prender a namorada de Thales. Na ocasião, nós apreendemos na residência da namorada de Thales documentos pessoais dele e, por isso, conseguimos identifica-lo como sendo o indivíduo conhecido como Irmão Mineiro. Eu nunca tive contato com o réu Thales. Eu não conhecia o réu Dário antes dos fatos." Reconheceu Dário. Declinou que "Quatro pessoas que foram presas na Rua Solimões e na Rua Pará identificaram o indivíduo conhecido como "Irmão Mineiro" como sendo o responsável pelo tráfico na região. Algumas dessas pessoas chegaram a mencionar o nome Thales como sendo o responsável pelo tráfico naquela região. Eles mencionavam Thales como sendo Irmão Mineiro. Alguns desses indivíduos informaram que Thales fazia parte do PCC. Nós não conseguimos apurar que posto Thales ocupava no PCC. Não foi feita nenhuma investigação nesse sentido. Aparentemente, ele era temido." Disse que "Quando nós detivemos Dário, estávamos somente eu e Wilson. Em seguida, chegou uma outra viatura em apoio. Nós não conseguimos deter os indivíduos

que adquiriram entorpecentes de Dário. O ponto de drogas fica em frente à residência de Dário. Não encontramos celular ou rádio comunicador com Dário. Não houve nenhuma averiguação com determinação de medidas tais como interceptação telefônica, busca e apreensão para averiguação da participação de Thales junto ao tráfico de entorpecentes. Na época em que a namorada de Thales foi presa, foram encontradas anotações supostamente referentes ao tráfico na residência dela. Pelo que sei, na época, não foi determinada nenhuma investigação para averiguar se as anotações partiram do punho do réu Thales."

No mesmo sentido o depoimento do policial civil Wilson.
Pois bem.

Do crime previsto no art. 33, caput, c.c. art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06 O art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal., dispõe que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".
Tem-se entendido que os agentes policiais podem ingressar em domicílio, sem autorização judicial, durante à noite, em hipótese de flagrante delito, sempre que amparados em fundada suspeita.

No caso do tráfico de entorpecentes, nas modalidades "guardar" e "ter em depósito", a consumação do crime protraí-se no tempo. Trata-se de crime permanente. Constitui, em tese, uma exceção à regra da inviolabilidade de domicílio.

Em julgado da Sexta Turma do E. Superior Tribunal de Justiça ficou assentado que:

"inda que seja incontroverso que nos delitos permanentes, como o de tráfico ilícito de drogas, o estado de flagrância se protraia ao longo do tempo, não se pode admitir que, com base em uma simples delação anônima, desamparada de elementos fundados da suspeita da prática de crimes, seja violado o direito constitucionalmente assegurado da inviolabilidade do domicílio" (DJe 03/09/2015).

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/R0, apreciando o Tema 280 da repercussão geral, firmou a seguinte tese:

"Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio - art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protraí no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos - flagrante delito, desastre ou para prestar socorro - a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial "a posteriori".

...

a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas "a posteriori", que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (RE 603.616 - Rel. Min. GILMAR MENDES - TRIBUNAL PLENO - j. 05/11/2015).

Consta do boletim de ocorrência que os fatos teriam ocorrido em 13.12.17, às 16 horas.

Os policiais civis presenciaram Dário vendendo entorpecentes a dois transeuntes. Havia flagrante em curso, o que legitima a entrada forçada em domicílio, mesmo sem mandado judicial.

Os entorpecentes e a quantia em dinheiro apreendida estava em "um saco plástico" localizado dentro de "um buraco na parede, do lado direito do corredor" por indicação do acusado.

Dário nunca explicou qual a procedência do numerário apreendido (R\$ 30,00). Tudo

indica que a quantia em dinheiro apreendida era proveniente da venda das drogas. Entendo, pois, que as provas coligidas em juízo, sob o crivo do contraditório, são suficientes para amparar a condenação de Dário por envolvimento na prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, deve ser afastada, pois o crime teria sido praticado nas imediações de uma Igreja Assembleia de Deus.

Nesse sentido:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORANTE. ANALOGIA IN MALAM PARTEM. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. MAUS ANTECEDENTES. REGIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amalhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação da acusada pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Por essas razões, mostra-se inviável a sua absolvição, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos.

2. Uma vez que, no Direito Penal incriminador, não se admite a analogia in malam partem e porque a hipótese dos autos (tráfico de drogas cometido em local próximo a igrejas) não foi contemplada pelo legislador no rol das majorantes previstas no inciso III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, deve ser afastada a causa especial de aumento de pena em questão.

3. Não há como ser reconhecida a incidência da minorante descrita no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas aos acusados possuidores de maus antecedentes.

4. As peculiaridades do caso concreto (maus antecedentes, quantidade e natureza da droga, bem como circunstâncias em que praticado o delito) justificam a imposição de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da reprimenda aplicada.

5. Ordem parcialmente concedida, para afastar a majorante prevista no inciso III do art. 40 da Lei de Drogas e, por conseguinte, reduzir a reprimenda da paciente para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa." (STJ - HABEAS CORPUS Nº 528.851 - SP (2019/0249970-0) - SEXTA TURMA - Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 05.05.2.020). O envolvimento de Thales nos crimes descritos na denúncia é questionável.

As provas produzidas não indicam que Thales teria participado ou concorrido de qualquer modo para a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Afora a confissão extrajudicial de Dário e diversos boletins de ocorrência que reportam fatos distintos, nada há que seja capaz de comprovar que Thales teria sido responsável por fornecer a Dário os entorpecentes apreendidos. As provas não demonstram que Dário agia em nome de Thales, como afirmara ao ser ouvido na Delegacia de Polícia.

Dário e Thales moravam no mesmo bairro - Vila Popular, em Várzea Paulista.

Conheciam-se. O reconhecimento efetuado na Delegacia de Polícia não tem nenhuma valia. Não se presta a comprovar que Dário trabalhava para Thales como tenta fazer crer a acusação.

Thales pode ser responsável por distribuir entorpecentes por toda a cidade. Fato é que nesses autos não está provado que ele teria sido o responsável por entregar ou por mandar entregar as drogas a Dário antes da apreensão.

A investigação iniciou-se a partir das fortes acusações de Dário. Encerrou-se após a juntada de documentos que nada provam. A participação de Thales no esquema de distribuição e venda de entorpecentes naquela localidade não está provada nesses autos.

O policial civil confirmou que "Não foi feita nenhuma investigação nesse sentido." Disse que "Não houve nenhuma averiguação com determinação de medidas tais como interceptação telefônica, busca e apreensão para averiguação da participação de Thales junto ao tráfico de entorpecentes. Na época em que a namorada de Thales foi presa, foram encontradas anotações supostamente referentes ao tráfico na residência dela". É impossível saber se as anotações encontradas com a namorada de Thales

faziam referência a Dário e às drogas a este confiadas. Não há prova da associação referida apenas em 13.12.17.

Em assim sendo, concluo que a absolvição de Dário e Thales por envolvimento na prática do crime previsto no art. 35, caput, c.c. art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, é de rigor.

Pelos motivos aqui expostos, entendo que não as provas são frágeis, de tal sorte que a absolvição de Thales por envolvimento na prática do crime previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/13 se impõe.

Passo a dosar a pena de Dário.

Em consonância com a diretriz estabelecida no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal uma vez que, muito embora o réu seja reincidente, quando dos fatos ele ostentava somente uma condenação com trânsito em julgado. Ademais, a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime não indicam a necessidade de majoração. A pena-base é calculada em 5 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Deve ser reconhecida a incidência da circunstância agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, pois, de acordo com a certidão de fls. 206/207, o réu é reincidente (autos nº 0035859-64.2005.8.26.0564 - pena extinta em 2.014). Por se tratar de reincidência específica, a pena é aumentada de 1/5 (um quinto), totalizando 6 (seis) anos de reclusão, mais 600 (seiscentos) dias-multa.

Nesse sentido:

"A reincidência específica é agravante que sempre determina a exacerbação da pena, inclusive em maior grau do que a recidiva genérica, por evidenciar que o réu persiste na senda do crime" (STF, HC 101918/MS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI).

Não há causas de aumento de pena a serem consideradas.

A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, deixa de ser aplicada em razão da reincidência.

Cada dia-multa terá o valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente no dia dos fatos, corrigindo-se em sede de execução, na forma do art. 43 da Lei nº 11.343/06.

O regime de cumprimento de pena será o fechado, já que o réu é reincidente, nos termos do disposto no art. 33, § 2º, "b", do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para:

(i). CONDENAR DÁRIO DA SILVA CARDOSO, RG nº 42.289.018, CPF nº 324.937.328-12, filho de Antonio Francisco Cardoso e de Luzia da Silva, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a uma pena de 6 (seis) anos de reclusão, mais 600 (seiscentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado;

(ii). ABSOLVER DÁRIO DA SILVA CARDOSO, RG nº 42.289.018, CPF nº 324.937.328-12, filho de Antonio Francisco Cardoso e de Luzia da Silva, da prática do crime previsto no art. 33, caput, e art. 35, caput, c.c. art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, o que faço com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e

(iii). ABSOLVER THALES MOREIRA RODRIGUES, vulgo "Irmão Mineiro", RG nº 42.257.448, CPF nº 459.201.948-20, filho de Robson Eduardo Ribeiro Rodrigues e de Gisele Silva Moreira, da prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e art. 35, caput, c.c. art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, e art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/13, o que faço com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Dário poderá apelar em liberdade, embora seja reincidente, pois não há razão para que seja decretada a prisão preventiva.

Dário compareceu a todos os atos do processo após ter sido revogada a prisão anteriormente decretada, de modo que nada justifica seja determinado novo encarceramento antes de transitada em julgado essa sentença.

Transitada em julgado esta sentença, lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados. Declaro o perdimento em favor da União, da quantia em dinheiro apreendida, nos

termos do art. 63 da Lei nº 11.343/06.

Após o trânsito em julgado, expeça-se a certidão de honorários em favor da patrona de Dário.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.I.C.

Varzea Paulista, 27 de abril de 2.022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA